

1502071-94.2020.8.26.0099

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... do acusado com relação ao delito de tráfico de drogas é medida impositiva, sob pena de ofensa ao princípio da correlação.

O artigo 384, do CPP, dispõe que encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502071-94.2020.8.26.0099

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2127631/2020 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 7461753 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA

PAULISTA, 76/20/124 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 2127631 - DEL.INV.GER.

BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON DA SILVA FIDELIS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

ROBSON DA SILVA FIDELIS foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, e do artigo 273, § 1º-B, incisos I, V e VI, do Código Penal, em concurso material de crimes, porque no dia 22 de maio de 2020, na rua José dos Santos, nº 200, Jardim Novo Mundo, nesta cidade e Comarca, tinha em depósito, com a finalidade de comércio, 01 litro de lança perfume, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, ROBSON DA SILVA FIDELIS, tinha em depósito, para fornecimento, venda ou entrega de qualquer forma a consumo, 04 caixas de duratestona, uma caixa de metandrostenolona e uma caixa de decaland depot, fármacos anabolizantes, medicamentos sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente, de procedência ignorada e sem licença da autoridade sanitária competente.

Devidamente notificado, o acusado apresentou defesa preliminar a fls. 118/119.

Recebida a denúncia ao 01 de outubro de 2021 (fl. 125), deu-se a regular instrução do processo.

Durante a instrução processual ouviram-se três testemunhas de acusação e duas da defesa. Ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 163).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, certa de que as provas dos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 194/199).

A defesa postulou a absolvição embasada na atipicidade dos fatos (fls. 202/212).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação é improcedente.

Ao acusado é imputada inicialmente a conduta prevista no artigo 33, caput, da lei de drogas, uma vez que, durante diligência realizada por policiais, eles apreenderam no interior de sua residência um litro de uma substância identificada, a priori, como lança-perfume.

Ocorre que, realizada a análise da substância apreendida, constatou-se a presença de cloreto de metileno/diclorometano, que se encontra descrita na Lista B1 (lista das substâncias psicotrópicas) e na Lista D2 (lista de insumos químicos utilizados para fabricação e síntese de entorpecente e/ou psicotrópicos - sujeitos a controle do Ministério da Justiça e Segurança Pública), da Portaria Anvisa 344/98, conforme laudo químico toxicológico colacionado aos autos às fls. 13/15.

A referida lista "D2" dispõe sobre "insumos químicos" e está alheia às disposições do Regulamento Técnico da Portaria 344/1998 da ANVISA, conforme excetuado em seu art. 108, segundo o qual tais substâncias químicas "encontram-se submetidas ao controle e fiscalização do Ministério da Justiça conforme Lei nº 9.017/95".

A Lei nº 9.017/95, na parte em que estabeleceu normas de controle e fiscalização sobre produtos e insumos químicos que possam ser destinados a elaboração da cocaína em suas diversas formas e de outras substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, foi revogada pela Lei nº 10.357, de 27/12/2001, que veio a estabelecer "normas de controle e fiscalização sobre produtos químicos que direta ou indiretamente possam ser destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem, dependência física ou psíquica".

A Lei nº 10.357/2001 estabelece:

"Art. 1º. Estão sujeitos a controle e fiscalização, na forma prevista nesta Lei, em sua fabricação, produção, armazenamento, transformação, embalagem, compra, venda, comercialização, aquisição, posse, doação, empréstimo, permuta, remessa, transporte, distribuição, importação, exportação, reexportação, cessão, reaproveitamento, reciclagem, transferência e utilização, todos os produtos químicos que possam ser utilizados como insumo na elaboração de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica.

§ 1º. Aplica-se o disposto neste artigo às substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica que não estejam sob controle do órgão competente do Ministério da Saúde.

§ 2º. Para efeito de aplicação das medidas de controle e fiscalização prevista nesta Lei, considera-se produto químico as substâncias químicas e as formulações que as contenham, nas concentrações estabelecidas em portaria, em qualquer estado físico, independentemente do nome fantasia dado ao produto e do uso lícito a que se destina.

Art. 2º. O Ministro de Estado da Justiça, de ofício ou em razão de proposta do Departamento de Polícia Federal, da Secretaria Nacional Antidrogas ou da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, definirá, em portaria, os produtos químicos a serem controlados e, quando necessária, promoverá sua atualização, excluindo ou incluindo produtos, bem como estabelecerá os critérios e as formas de controle.

Art. 3º. Compete ao Departamento de Polícia Federal o controle e a fiscalização dos produtos químicos a que se refere o art. 1º. desta Lei e a aplicação das sanções administrativas decorrentes".

Além disso, dispõe que as pessoas físicas ou jurídicas que pretendam exercer qualquer das atividades relacionadas, sujeitas a controle e fiscalização, necessitam cadastrar-se e requerer licença de funcionamento ao Departamento de Polícia Federal (art. 4º), devendo todas as partes envolvidas possuir licença de funcionamento, exceto quando se tratar de quantidades de produtos químicos inferiores aos limites a serem estabelecidas em portaria do Ministro de Estado da Justiça (art. 6º), dispondo, também, sobre as infrações administrativas (art. 12) e medidas punitivas aplicáveis (art. 14), além do saneamento de irregularidades (art. 15), nada restando a respeito de responsabilidade penal dos infratores.

A Lei nº 11.343/2006, por sua vez, estabelece:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

A expressão "drogas", para os fins do art. 33 referido, vem complementada com a norma explicativa contida no parágrafo único do art. 1º, da Lei de Drogas, a saber: "Para fins desta Lei, considera-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificadas em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União".

Destarte, o "Cloroeto de Metileno" ou "Diclorometano", substância química relacionada na Lista "D2", que versa sobre os insumos químicos utilizados como precursores para fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos, sujeitos ao controle do Ministério da Justiça, por si só não é considerado droga ilícita, para os fins da Lei nº 11.343/2006, porquanto, repete-se, livremente comercializável por pessoas físicas e jurídicas devidamente cadastradas e autorizadas, sob o controle e fiscalização da Polícia Federal. Além disso, não é indicado como substância capaz de causar dependência física e/ou psíquica. Logo, forçoso concluir que o fato relatado na denúncia e imputado ao acusado, mais precisamente ter em depósito, para consumo de terceiro, substância entorpecente que causa dependência física e/ou psíquica, é atípico, uma vez que a substância apreendida em sua casa (cloroeto de metileno) é considerada insumo destinado à preparação de drogas.

Portanto, referida substância, apesar de não causar dependência física ou psíquica, está incluída na lista de insumos destinados à síntese de entorpecentes (Portaria Anvisa n. 344/98, Lista D2, item 5). Sendo assim, sua compra, venda, fornecimento ou aquisição, ainda que gratuitas, não se enquadram no delito tipificado no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/06, e sim no do § 1.º, I, a saber:

"Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas".

Lado outro, conforme se depreende do exame pericial, repise-se, a substância apreendida não é entorpecente. A par disto, o fato é que acusado não foi denunciado por uma das condutas previstas no artigo 33, § 1º, que descreve condutas com objeto material diverso, ou seja, "matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas", mas sim no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, que têm como objeto material somente as drogas.

Dessa maneira, inexistindo a apreensão de substâncias descritas na lista proibitiva da norma penal em branco complementar ao artigo 1º, da lei de drogas, não há como se falar em crime, motivo pelo qual a absolvição do acusado com relação ao delito de tráfico de drogas é medida impositiva, sob pena de ofensa ao princípio da correlação.

O artigo 384, do CPP, dispõe que encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 05 (cinco) dias, se em virtude deste houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

Pontue-se que após o interrogatório do acusado, na audiência realizada aos 25/01/2022 (termo de fl. 163), fora dada oportunidade às partes para se manifestarem sobre novas diligências, ocasião em que o órgão acusatório nada requereu.

Se não bastasse, finda a instrução, o Ministério Público ao receber o processo, ao invés de aditar a denúncia, limitou-se a apresentar as alegações finais, sem fazer qualquer menção à nova imputação versada em razão da prova produzida, deixando, assim, de exercer a *mutatio libelli*, postulando apenas a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

Destarte, haveria necessidade de aditamento da inicial que não fora executado pelo Ministério Público. Assim, ultrapassada a oportunidade de aditamento, por consequência, desencadeia-se a absolvição, com base no princípio da congruência. De acordo com o princípio da correlação, o fato imputado ao acusado na denúncia deve guardar perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo juiz na sentença, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Sobre o tema, trago à baila os ensinamentos do renomado Mirabete:

"...deve haver uma correlação entre a sentença e o fato descrito na denúncia ou na queixa, ou seja, entre o fato imputado ao réu e o fato pelo qual é condenado..."

"...representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa e qualquer distorção, sem observância dos dispositivos legais cabíveis, acarreta a nulidade da decisão." (cf. Mirabete in "Código de Processo Penal Interpretado", Editora Atlas, 8ª ed., p. 831).

E ainda, as lições do saudoso Magalhães Noronha:

"Denúncia (e diga-se o mesmo da queixa) e sentença devem guardar entre si uma certa relação, o que é bem compreensível, pois naquela o titular da ação - o Ministério Público -, isto é, o Estado-Administração expõe ao Estado-Juiz a pretensão punitiva, descrevendo o fato criminoso com todas suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou os caracteres que o identifiquem e a classificação do crime.

De grande valia, cito os ensinamentos da ilustre Ministra do STJ, Jane Silva (Desembargadora convocada deste E. TJMG), expendidos no julgamento do HC 47838:

"Um dos princípios, que deve informar a regularidade da sentença é o princípio da correlação entre o fato descrito na denúncia ou na queixa e aquele fato pelo qual o acusado é condenado, sendo tal princípio uma das maiores garantias do direito de ampla defesa outorgado, constitucionalmente, a todo e qualquer réu.

Assim, não pode o Juiz, em princípio, condenar um réu por um fato pelo qual ele não foi acusado, pois teríamos uma condenação extra petita ou ultra petita ou ainda condená-lo por um fato mais grave (*in pejus*), assim como não pode o Juiz, sob pena de ferir o direito inderrogável da acusação, deixar de examinar qualquer infração penal descrita na peça acusatória, sob pena de proferir decisão citra petita, acarretando, em qualquer dos casos, a nulidade da própria sentença".

Nesse sentido, eis a Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO - NULIDADE DO DECISUM POR OFENSA AO ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INOCORÊNCIA - INÉRCIA DO PARQUET - RECURSO NÃO PROVIDO. - O réu se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da capitulação a eles conferida na denúncia, sendo perfeitamente admissível a "mutatio libelli" (art. 384, CPP), desde que o Ministério Público a viabilize após a instrução criminal, dentro do prazo legal. - Se o Parquet se mantém inerte, não há como condenar os acusados de modalidades criminosas diversas das descritas na denúncia, sob pena de ofensa ao princípio da correlação entre a imputação e a sentença. (TJ-MG - APR: 10718120008492001 MG, Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 24/06/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/07/2014).

Não obstante, ainda que fosse o caso de se apreciar a conduta do acusado como descrita no § 1º, do artigo 33, da lei especial, apenas por argumentação, a ação igualmente não seria procedente.

Durante seu interrogatório o acusado negou a prática da infração.

Muito embora tenha confirmado a apreensão de um litro do produto classificado como cloreto de metileno, Robson defendeu-se dizendo que a substância é utilizada em seu trabalho de vidraceiro, bem como que ela é adquirida de forma legal no comércio em geral.

Sua negativa não pode ser contrariada.

Isso porque as testemunhas ouvidas, tanto de acusação como de defesa, ratificaram a sua versão.

Solange, genitora do acusado, disse que de fato o produto em questão encontrava-se em sua casa, na garagem do imóvel, lugar onde seu marido trabalha como vidraceiro. Salientou, ainda, que referida substância é utilizada para remoção de cola em espelhos e é adquirida livremente em loja de policarbonato.

No mesmo sentido foram as palavras de Rogério, padrasto do acusado. Ele declarou que é vidraceiro e que no exercício de sua profissão utiliza o cloreto de metileno para remover a etiqueta do vidro. Confirmou, ainda, que o produto era de sua propriedade e que o comprou no mercado livre. Por fim, informou que a embalagem contendo o cloreto estava guardada numa prateleira existente na garagem de seu imóvel, juntamente com outros produtos igualmente utilizados em seu trabalho.

A par disto, às fls. 161 a defesa colacionou aos autos comprovação da condição de microempreendedor individual de Rogério, declarando sua ocupação principal como vidraceiro.

Lado outro, à fl. 160 apresentou nota fiscal de compra de uma garrafa de cloreto de metileno, corroborando com a versão do acusado de que o produto possui venda permitida.

Destarte, sua absolvição se impõe.

Prosseguindo, a ação também não procede quanto ao crime tipificado no artigo 273, § 1º, B, do Código Penal.

Conforme a narrativa da denúncia, o acusado, no dia 22/05/2020, tinha em depósito, para fornecimento, venda ou entrega de qualquer forma a consumo, vários tipos de anabolizantes (4 caixas de duratestona, 01 caixa de metandrostenolona e 01 caixa de decaland depot).

Os exames periciais concluíram que as substâncias detectadas nas amostras em questão pertencem ao grupo dos anabolizantes incluídos na lista C5 (sujeitos a receita de controle especial em duas vias) da Portaria SVS/MS nº 344/98, bem como que os itens 02 e 03 (metandrostenolona e decaland depot) não possuem registro na ANVISA.

O acusado em seu interrogatório judicial admitiu a propriedade dos anabolizantes. Contudo, negou a intenção de comercializá-las.

Robson defendeu-se dizendo que comprou os fármacos na academia que frequentava e que os usava há algum tempo, visando acelerar o seu metabolismo. Argumentou, ainda, que desconhecia serem anabolizantes, bem como que sua venda era proibida.

Sua negativa não pode ser contrariada. Isso porque as provas orais colhidas não foram suficientes para demonstrar que os anabolizantes apreendidos em seu poder

estavam destinados ao comércio ilícito.

Os investigadores de polícia Eduardo e Edilson apenas informaram que durante diligência efetuada na casa do acusado localizaram, no interior de uma mochila, os fármacos apreendidos. No mais, não apresentaram nada em concreto que pudesse indicar que aqueles anabolizantes estariam destinados à venda pelo acusado. Pois bem.

Dispõe o artigo 273, § 1º-B, do Código Penal:

“§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. (...)

§ 1º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no § 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições:

I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente; [...]

V - de procedência ignorada e

VI - adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente.

A denúncia indica a posse das substâncias com o fim de entregar a terceiros.

A versão dos policiais civis não deixa dúvida quanto à posse pelo acusado.

Contudo, dúbio o destino, o que é imprescindível para a tipificação do tipo penal denunciado.

Saliente-se que não havia notícia anônima de prática de mercancia ilícita pelo acusado. A par disto, a apreensão somente ocorreu porque o acusado foi preso noutra cidade pela prática de tráfico de drogas, ocasião em que ele estaria na posse de crack. Em razão disso, os policiais resolveram por bem revistar a sua residência, quando então localizaram os anabolizantes.

Por outro lado, a quantidade apreendida é compatível com a posse para consumo próprio, bem como inexistente nos autos qualquer demonstração que indique que o acusado não tivesse condições financeiras de adquirir, para seu uso, os medicamentos apreendidos.

Em caso análogo julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na apelação nº 0001713-27.2014.8.26.0646, demonstrou-se ser comum usuários desses medicamentos fazerem uso em ciclos, com utilização combinada de anabolizantes, por várias semanas seguidas, o que induz à conclusão de que a quantidade apreendida não extrapola o uso ordinário por uma pessoa.

Pontue-se que em seu interrogatório o acusado declarou que já utilizava os anabolizantes há alguns meses.

A condenação não pode firmar-se em presunção, ilação, conjectura, probabilidade.

Isso porque, para a caracterização do crime em comento, previsto no artigo 273, parágrafo 1º-B, incisos I, V e VI, do Código Penal, seria imprescindível que a prova indicasse com segurança que o acusado importava, vendia, expunha à venda, tinha em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuía ou entregava a consumo o produto sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente, ou de procedência ignorada e ainda, adquirido de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente.

Destarte, ao término da instrução processual, considerando-se a diminuta quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, a par da ausência de qualquer notícia de que o acusado estaria comercializando tais produtos, surgem dúvidas de que ele iria comercializar os anabolizantes.

O sistema penal assenta-se na presunção de inocência e, bem por isso, para a condenação a prova há de ser plena e convincente, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, consagrando-se o princípio do in dubio pro reo, contido no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

Apelação Criminal – Posse ilegal de arma de fogo e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais - Sentença parcialmente condenatória - Recurso do Ministério Público objetivando a condenação do apelado também pelo crime previsto no artigo 273, § 1º-B, incisos I e II, do Código Penal – Inadmissibilidade – Correta a r. sentença monocrática

absolutória em relação ao crime acima descrito, tendo em vista a patente ausência de provas de que o medicamento proibido seria destinado à comercialização - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0002411-26.2015.8.26.0637; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020)

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de ABSOLVER ROBSON DA SILVA FIDELIS, qualificado nos autos, das imputações do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 e artigo 273, § 1º-B, incisos I, V e VI, do Código Penal, que lhe foram feitas, o que faço com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código Processual Penal. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Bragança Paulista, 17 de março de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA